

1501180-44.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... militares evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Importante destacar que a lei pune o tráfico ilícito de drogas em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501180-44.2022.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501180-44.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241441/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 27193321 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2241441 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHESTER FERREIRA GONÇALVES

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

SHESTER FERREIRA GONÇALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na figura típica descrita no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 11h57, na Rua José Aguiar Fogaça, nº. 469, do Bairro Jardim Rosa Garcia II, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo 11 (onze) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 6,2 gramas e 07 (sete) porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto aproximado de 1,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 71) e apresentou defesa prévia (fls. 76/78).

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2022 (fls. 89/90) e o réu foi citado (fl. 100).

Durante a audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual, passou-se aos debates (fls. 106/111).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de RENAN PAES DE ABREU, o qual, segundo consta da peça inicial acusatória, transgrediu o preceito primário da norma penal incriminadora inserida no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante disposta no artigo 61 inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, verifica-se que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente demonstrados, no entanto, de rigor o parcial acolhimento da pretensão punitiva, a fim de que seja o réu condenado pela prática do delito a ele atribuído, mas com o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e da circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fl. 12, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 13, comprovante de depósito judicial de fl. 50, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 66/68 e pela prova oral colhida.

De igual modo, a autoria é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passo à análise da prova oral, notadamente aquelas colhidas em audiência.

Durante a instrução, a testemunha JOSÉ MARIO CAVALHEIRO DEL HOMO, policial militar, narrou que na data dos fatos, durante patrulhamento pelo Bairro Jardim Rosa Garcia II, ao passarem pela Rua Orlando Salmasi, sua equipe visualizou o acusado aproximar-se de um veículo do modelo Gol e de cor prata. Observaram que o réu falou algo para o condutor do referido automóvel. Por se tratar de um local conhecido pelo intenso comércio de drogas, deliberaram pela abordagem do acusado que, por seu turno, evadiu-se por meio de um campo ali existente. A equipe policial fez um retorno em volta do campo e logrou alcançar o réu na Rua José Aguiar Rost. Antes da abordagem, o depoente e seu parceiro perceberam que Shester tentou jogar uma quantia em dinheiro e colocou a mão na boca. Através de procedimento de revista pessoal, dentro da pochete utilizada pelo acusado foram apreendidas uma porção de crack e onze porções de cocaína. Posteriormente, no Pronto Socorro o réu expeliu seis porções de crack que havia engolido. No local da abordagem a equipe encontrou parte do dinheiro dispensado pelo réu, consistente na quantia de duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos. Diante dos fatos, o réu foi conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura da ocorrência. Destacou, por fim, que ao ser indagado, o réu confessou a prática do tráfico de drogas e que também era usuário. O policial militar JÚLIO SOARES DE OLIVEIRA MARTINS LOPES ratificou na íntegra o depoimento de seu colega de farda José Mário. Acrescentou que ambos flagraram o acusado em poder de uma porção de crack e onze porções de cocaína, além de certa quantia em dinheiro. O réu confessou a prática da mercancia ilícita. No hospital, o acusado ainda informou à equipe que, além das porções de drogas já apreendidas, havia engolido seis porções de crack, as quais foram por ele expelidas e devidamente apreendidas.

Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu SHESTER FERREIRA GONÇALVES manifestou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 07). Durante seu interrogatório judicial, ouvido sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, disse que atualmente reside no Bairro Jardim Thomaz Guedes e trabalha em uma serralheria. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Acerca dos fatos,

confessou a prática do delito a ele atribuído. Disse que realizava o comércio de drogas no local havia aproximadamente um mês e alguns dias. Utilizava o dinheiro obtido com a venda para conseguir drogas para seu consumo. Já foi internado para tratamento de seu vício. Ainda faz uso de crack.

Pois bem. Finalizada a instrução, o conjunto probatório leva à conclusão de que o réu é responsável pela prática do delito a ele atribuído na denúncia; a assertiva é lógica e harmoniza-se com os elementos colhidos no decorrer do feito.

As porções de drogas encontradas em poder do acusado, as circunstâncias da prisão em flagrante e as declarações dos policiais militares evidenciam a finalidade de tráfico.

A prova oral colhida, à luz do contraditório e as demais provas acostadas aos autos, formam um conjunto apto à formação de um juízo de convencimento quanto ao tráfico exercido pelo réu.

Importante destacar que a lei pune o tráfico ilícito de drogas em qualquer de suas condutas, típicas e exclusivas. Em tema de entorpecente, a conduta descrita na denúncia, qual seja de “trazer consigo”, sem autorização legal ou regulamentar, a droga proibida, basta para integrar a figura criminosa do tráfico ilícito.

Cabe também mencionar que nenhuma restrição merece os depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e prisão do acusado, mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada acerca de suas condutas. Nesse sentido:

“... nenhum impedimento legal existe ao testemunho de investigadores e pessoas ligadas à polícia. Seus depoimentos devem ser considerados, examinados e pesados em cada caso, como o de outra testemunha qualquer. Nunca, porém, sumariamente afastados como de todo imprestáveis. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória.” (Ap.Crim. 103.701 TJSP);

“... a simples condição de policial não torna a testemunha suspeita ou impedida” (STF – RT 68/64);

“... não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito.” (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221).

Não bastasse, o réu confessou a prática delituosa, dando detalhes de sua empreitada, notadamente em relação aos valores das porções e desde quando se envereda na mercancia espúria.

O quadro probatório é, pois, eficaz e conclusivo em relação à materialidade e autoria dos fatos narrados.

Com efeito, bem delineado nos autos que no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 11h57, durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Rosa Garcia II, ao passarem pela Rua Orlando Salmasi, a equipe da Polícia Militar avistou o acusado aproximar-se de um veículo e conversar com o seu condutor.

O local apontado é conhecido pelo intenso comércio espúrio ali praticado, razão pela qual os policiais deliberaram pela abordagem.

Ao notar a aproximação da viatura, o réu passou a caminhar por um campo existente no local e somente foi possível sua abordagem na Rua José Aguiar Fogaça. Ainda, antes de ser abordado, o réu foi flagrado tentando dispensar certa quantia em dinheiro, bem como foi observado enquanto colocava algo na boca.

Na revista pessoal do acusado, dentro de uma pochete que portava, foram apreendidas porções de cocaína e crack. Questionado, o réu confessou a venda de drogas e, por isso, foi conduzido ao hospital do Município, local em que ainda expeliu outras seis porções de crack que havia engolido. Posteriormente, todos foram à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

Convém lembrar não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a

terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado. Este é o caso dos autos em atenção aos elementos de informação aqui coligidos.

A título de argumento, sequer seria o caso de desclassificação do delito atribuído ao réu para a figura típica disposta no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. De se ver que a quantidade de drogas apreendida não se coaduna com a mera posse para consumo do agente.

Não fosse isso, é indene de dúvidas que muitos usuários entram no tráfico para custear a compra de drogas para uso próprio (a denominada figura do “traficante-usuário”), situação que, por si só, não afasta a ilicitude do fato.

Ainda, o fato de ser eventualmente usuário, afirmação feita em juízo pelo acusado, não afasta a sua relação com o comércio ilícito de drogas, pelo contrário, facilita tal espécie de atuação, diante do irrestrito acesso a outros usuários, seus consumidores e traficantes.

Neste sentido, inclusive: “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade.” (RJTJSP 101/498).

Em suma, a Defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento que fosse capaz de, ao menos, colocar em dúvida algum ponto do acervo probatório constituído nestes autos, o qual se revela farto e demonstra com riqueza de detalhes toda a ação delituosa.

Por fim, conforme já apontado no início da fundamentação, apenas não há se falar na presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto a entidade informada à fl. 69 dista a mais de duzentos metros do local da prisão do acusado, extensão que também se revela superior ao espaço físico entendido como “imediações”, a qual traz a ideia de acesso rápido e imediato. Neste sentido: “TJ-SP - Apelação nº 0004512-19.2014.8.26.0363; 11ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Ivana David; Origem: Comarca de Mogi-Mirim; Julgamento: 04.05.2016; Publicação: 24.05.2016”.

Inconteste, pois, a ocorrência de todos os elementos típicos, subjetivos e objetivos, necessários para a responsabilização do réu pela prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, decotando, contudo, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma legal.

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira etapa, atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, inexistente circunstância judicial negativa a influir em desfavor do acusado. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber: 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade e natureza da droga apreendida serão consideradas na terceira etapa da dosimetria da pena, notadamente para a análise da fração adequada para a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes.

Ressalvado o entendimento adotado outrora, adequando-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

“Em relação à agravante prevista no art. 61, I, “j”, do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva.” (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

“Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.” (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexos causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5 GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “j” (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

O réu confessou a prática do delito, fazendo jus à circunstância atenuante respectiva (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP e Súmula nº 545 do STJ). No entanto, deixo de considerá-la, em atenção à Súmula nº 231 do STJ, pois a pena está em seu patamar mínimo, motivo pelo qual a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena.

Por outro lado, concedo a benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, devido à primariedade do acusado e a ausência de elementos que indiquem fazer parte de organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.

No tocante à fração a ser adotada, reduzo a pena em 2/5 (dois quintos), gerando a reprimenda legal de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 300 (trezentos) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena.

Anoto que não é cabível redução maior em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, a saber: 11 (onze) porções de cocaína, com peso líquido de 1,2 gramas; e 07 (sete) porções de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido de 1,35 gramas; as quais devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

De fato, embora em quantidade não expressiva, o crack e a cocaína possuem efeitos deletérios àqueles que deles fazem uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresentam extremamente nocivos à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional.

Por isso, entendo que a fração adotada revela-se condizente e justa em consonância com a sua reprovação social.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Atentando-se à primariedade do acusado, considerando, ainda, que “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.” (§ 5º ao artigo 112, da lei 7.210/1984 – LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019), bem como o entendimento pacificado nas Cortes Superiores, FIXO O REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, letra “c” do Código Penal.

Ainda, em atenção ao entendimento firmado no HC nº 596.603/SP do E. STJ, reputo presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de modo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes em: I) prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de execução criminal; e II)

limitação de fim de semana.

Diante da substituição operada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Atento ao regime de cumprimento e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, bem como a sua substituição por penas restritivas de direito, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a imposição da custódia preventiva. De fato, não há nos autos elementos seguros a indicar que o réu, de alguma forma, possa trazer risco à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal ou, ainda, que vá se furtar da aplicação da lei penal. Deste quadro, DEFIRO o recurso em liberdade.

Ausentes nos autos informações acerca da situação econômica do réu, ESTABELEÇO o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, decotando a circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia para CONDENAR o réu SHESTER FERREIRA GONÇALVES, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, além do pagamento de multa de 300 (trezentos) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa aplicada, em entidade a ser designada pelo juízo da Execução Criminal e limitação de fim de semana.

CONFORME FUNDAMENTADO, DEFIRO O APELO EM LIBERDADE.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, caso tal medida ainda não tenha sido providenciada.

DECLARO o perdimento do numerário apreendido, qual seja a quantia de R\$ 260,65 (auto de exibição e apreensão de fl. 12 e comprovante de depósito judicial de fl. 50), em favor da União, para ser revertido diretamente ao Funad, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal c.c. o artigo 63 e parágrafos, da Lei nº 11.343/06.

O réu está assistido por Defensor nomeado, circunstância que deixa presumir que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Assim, incabível se mostra a condenação ao pagamento das custas, observando a Gratuidade da Justiça a ele concedida às fls. 89/90.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao Advogado nomeado para patrocinar os interesses do réu (fl. 79), nos termos do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente e demais comunicações necessárias.

P.I.C.

Tatui, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA